

1501615-29.2021.8.26.0126

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIO HENRIQUE GEBRAN SCHIRMER

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2295530/2021 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 21104240 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 3311/21/301 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2295530 - DEL.POL.CARAGUATATUBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, Caraguatatuba-SP - cep 11660-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501615-29.2021.8.26.0126 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501615-29.2021.8.26.0126

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2295530/2021 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 21104240 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 3311/21/301 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2295530 - DEL.POL.CARAGUATATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO ALVES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIO HENRIQUE GEBRAN SCHIRMER

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo do Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor de LEANDRO ALVES DOS SANTOS, já qualificado, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi deduzida nos seguintes termos:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28 de OUTUBRO de 2021, período da tarde, no interior da residência situada na rua Flora Atlantica, 70, Olaria, nesta cidade, LEANDRO ALVES DOS SANTOS, qualificado a fls.02, guardava, para fins de

tráfico, VINTE E OITO porções de Cannabis sativa - L, vulgarmente conhecida como "maconha" e CENTO E OITENTA porções de cocaína sob a forma de "crack", substâncias entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. laudo de exame químico toxicológico - fls.12-13). Segundo se apurou, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro do Olaria onde verificaram o denunciado em atitude suspeita, pois o local já conhecido como sendo ponto de tráfico de droga. Na abordagem feita pelos policiais militares nada de ilícito foi localizado com LEANDRO ALVES DOS SANTOS, mas ao solicitaram o RG do autor para identificação, o denunciado disse quem estaria ele, porém soube dizer o número do documento aos policiais. Ao informar o seu número de RG para os policiais militares, imediatamente os agentes fizeram uma pesquisa via COPOM onde foi verificado que o DENUNCIADO seria procurado da justiça. A esposa do denunciado LEANDRO estava presente na abordagem e informou que o documento de LEANDRO estava em sua casa na mesma rua. Na oportunidade, iniciou-se um breve diálogo entre a esposa do autor e a guarnição policial, sendo certo que foi perguntado a eles se havia algo de ilícito na residência. LEANDRO ALVES DOS SANTOS disse que sim e pediu que a sua esposa pegasse os entorpecentes, informando inclusive onde as drogas estariam guardadas (dentro de um compartimento de um Rack que estava no quarto do casal). Diante de tal informação o policial Alexandre acompanhou a esposa do denunciado até a residência onde foi entregue um saco de salgadinho e dentro dele estavam os entorpecentes destinados a venda. Dentro do saquinho havia 180 pedras de crack (54,62 gramas), 28 tabletes de maconha com peso de (126,60 gramas) e a quantia de R\$ 570,00 em notas de 20,10 e 5 reais" (fls. 03-04).

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva (fls. 62-63). A defensoria apresentou embargos de declaração da decisão (fls. 66-68), os quais foram rejeitados (fl. 81).

A denúncia foi recebida em 17 de novembro de 2021 (fls. 109-110).

O acusado apresentou resposta à acusação (fls. 124-125) alegando, em síntese, matérias que são atinentes ao mérito.

O recebimento de denúncia foi ratificado, sendo designada data para realização de audiência de instrução e julgamento (fls. 126-128).

Foi produzida a prova oral, com a oitiva das testemunhas, bem como a inquirição do acusado, por meio de sistema de gravação audiovisual, em audiência realizada por videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020 (fls. 154-155).

Encerrada a fase de instrução, o i. representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. Sustentou que aplicável a confissão espontânea.

A defesa, por sua vez, apresentou alegações finais sustentando que as provas são ilícitas, em razão de violação de domicílio e do sigilo telefônico do acusado.

Argumentou que o acusado negou que tenha consentido com busca em seu celular, sendo esta procedida de forma ilegal. Alegou, também, que o consentimento para busca domiciliar foi decorrente de constrangimento, sob a ameaça de que a filha do acusado seria levada ao conselho tutelar. Desta maneira, pugnou pelo reconhecimento da ilicitude das provas. Afirmou que, sendo reconhecida a ilicitude das provas, inexistem provas suficientes à condenação. Subsidiariamente, postulou para que a pena base seja fixada no mínimo legal e na segunda fase a reincidência seja compensada com a confissão espontânea.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

1. Inexistem alegações a respeito do trâmite processual e, tampouco, há, neste contexto, matéria a se conhecer de ofício, dado que o feito transcorreu regularmente.

Por esta razão, possível o julgamento do mérito.

No ponto, destaque-se que a alegação de ilicitude de provas será analisada juntamente com o mérito, na fase de cotejo do arcabouço probatório.

2. Antes, todavia, são necessários alguns apontamentos a respeito do standard probatório reclamado para a legitimação de uma condenação na seara penal. Afinal,

a imposição de quaisquer penalidades pressupõe, para sua validade, não apenas o efetivo exercício de coerção, antes exigindo, também, que o poder estatal esteja assentado em premissas discursivas de legitimação (a respeito ver: FORST, Rainer. Justificação e Crítica – perspectivas de uma teoria crítica da política. São Paulo: Editora Unesp, 2018; ARENDT, Hannah. Sobre a Violência. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009). Trata-se, ao fim e ao cabo, da necessidade de justificação do poder, o que é inerente ao próprio conceito de democracia.

Nesse contexto, a imposição de penas exige que o decreto condenatório esteja alicerçado em provas e fundamentos que conduzam a uma conclusão que se coloca além de um patamar de 'dúvida razoável' a respeito da existência e autoria delitivas. Neste sentido é a doutrina de Gustavo Badaró, ao afirmar que, conquanto a atividade probatória ambicione a reconstrução de fatos históricos – os quais, por evidente, não podem ser reproduzidos de maneira idêntica e absoluta –, nas hipóteses de procedência da pretensão punitiva deverá ser alcançada uma conclusão assentada em um "altíssimo grau de probabilidade" de ocorrência dos fatos tais como narrados na denúncia (BADARÓ, Gustavo. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Editora RT, 2003, p. 62). Isto se traduz, em síntese, em afirmar que a possibilidade de condenação está à mercê da maior ou menor solidez do contexto probatório que se está inserido, sendo, no entanto, necessário, sempre, um mínimo de lastro probatório para que se possa proferir um decreto condenatório.

Feitas tais considerações gerais a respeito dos níveis probatórios necessários a comportar um decreto condenatório, passo ao exame dos elementos de prova existentes nos autos para atestar a comprovação, ou não, da prática dos delitos imputados aos réus.

3. Analisando-se os elementos de informação, bem como a produção de provas em juízo, verifico que a materialidade está demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13-14), Auto de Constatação Preliminar (fls. 15-16), Auto de prisão em flagrante (fl. 04), laudos periciais dos entorpecentes apreendidos (fls. 143-145) e, ainda, pela prova oral produzida em juízo.

4. Passo à análise da autoria.

Nesse contexto, a testemunha Alexandre (policial militar) narrou, em síntese, que estava em patrulhamento, em local conhecido pela venda de entorpecentes, quando abordaram 03 indivíduos, sendo que nada de ilícito foi encontrado com eles. Porém, um deles – o acusado – estava com mandado de prisão em aberto. Durante a abordagem, o acusado começou a receber várias mensagens em seu aparelho celular. Em seguida, o acusado confessou que realizava o tráfico e indicou aos policiais que havia drogas em sua residência. Diante deste contexto, a esposa do acusado franqueou a entrada no local, onde foram encontradas as drogas objeto dos autos. Relatou que o acusado confessou estar em posse dos entorpecentes em sua casa, dizendo que sua responsabilidade era fornecer as drogas às 'lojinhas'. Esclareceu que as drogas foram encontradas em um pequeno cômodo da casa, em vestes que estavam dentro de um rack. Disse, ainda, que as mensagens do celular estavam abertas.

A testemunha Lírio Trigo (policial militar) afirmou que estava em patrulhamento juntamente com seu companheiro, quando abordaram 03 pessoas e nada de ilícito foi encontrado. Durante a diligência, verificaram que Leandro era procurado. Em seguida, começaram a chegar várias mensagens no celular do acusado. Então, o acusado confessou que participava do tráfico, sendo que seria o responsável pela distribuição das drogas aos pontos de venda. Afirmando que seu companheiro se dirigiu à residência do acusado, onde a droga foi encontrada.

A informante Elenice (esposa do acusado) afirmou estava em casa fazendo o almoço, quando uma amiga lhe chamou, dizendo que o acusado (seu marido) havia sido preso. Então, saiu para ver o que estava acontecendo e foi informada pelos policiais que o acusado estaria fumando maconha, o que foi negado por ela. Em seguida, buscou o RG de seu marido, em sua casa, e entregou aos policiais, os quais teriam dito que o acusado estava sendo procurado pela polícia. Disse que ficou muito nervosa com a situação, porque os policiais teriam dito que se ela não falasse nada levariam sua filha ao conselho tutelar. Disse que estava muito nervosa, mas acompanhou a busca em sua residência. Esclareceu que não lhe ameaçaram de prisão, mas disseram que iriam levar sua filha ao conselho tutelar. Afirmo que foi ela quem ligou para o

acusado durante a abordagem,

Em seu interrogatório, o acusado disse que estava na ponte, juntamente com um amigo e seu primo, e foram abordados pela polícia, porque seu primo havia fumado maconha, pouco antes. Durante a abordagem, os policiais verificaram seus dados e disseram que ele estava sendo procurado. Em seguida, os policiais viram seu celular tocando e lhe questionaram sobre a situação. Então, o acusado confirmou que guardava drogas em sua casa. Disse que indicou o local onde as drogas estavam e que iria entregar as drogas naquele mesmo dia, sendo que toda a situação transcorria sem o conhecimento de sua esposa. Afirmou que, durante a abordagem, os policiais pegaram seu celular e viram as conversas. Relatou que autorizou a entrada da polícia em sua residência somente depois que viram seu celular. Disse, ainda, que sua esposa não sabia da droga, porque pegou as substâncias naquele mesmo dia e, também neste mesmo dia, as entregaria.

5. Passo à análise da tese de ilicitude probatória. No ponto, a defesa argumenta que o sigilo das comunicações telefônicas do acusado teria sido violado, na medida em que os policiais teriam acessado às mensagens do aparelho do acusado, sem a devida autorização. Sustenta, também, que as demais situações seriam decorrentes desta primeira ilegalidade e, por este motivo, não poderiam ser aceitas, em razão da invalidade inicial da cadeia probatória, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

5.1. Ao regulamentar a matéria, o art. 157, do CPP, estabelece que “São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.”. Além disso, o art. 5º, XII, da CF, garante que “XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que é inválida a verificação de mensagens durante abordagem, sem que seja conferida devida autorização para tal.

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ACESSO A DADOS CONTIDOS NO CELULAR DO RÉU. RESERVA DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Os dados armazenados nos aparelhos celulares envio e recebimento de mensagens via SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens, fotografias etc. , por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, são invioláveis, nos termos em que previsto no inciso X do art. 5º da Constituição Federal, só podendo, portanto, ser acessados e utilizados mediante prévia autorização judicial, com base em decisão devidamente motivada que evidencie a imprescindibilidade da medida, capaz de justificar a mitigação do direito à intimidade e à privacidade do agente. 2. Por ocasião da prisão em flagrante do paciente, o celular que portava foi apreendido, desbloqueado e nele verificada a existência de fotos que indicavam a possível prática do delito de tráfico de drogas. Ainda antes do acesso aos dados constantes do seu celular, os agentes estatais procederam à revista pessoal do acusado, não encontraram nada de ilícito em seu poder, tampouco no interior do seu veículo automotor. 3. Pelos documentos constantes dos autos, não se verifica, portanto, nenhum argumento ou situação que pudesse justificar a necessidade e a urgência, em caráter excepcional, de as autoridades policiais poderem acessar, de imediato (e, portanto, sem prévia autorização judicial), os dados armazenados no aparelho celular do paciente. Ao contrário, pela dinâmica dos fatos, o que se depreende é que não haveria nenhum prejuízo às investigações se os policiais, após a apreensão do telefone celular, houvessem requerido judicialmente a quebra do sigilo dos dados nele armazenados. 4. Pela leitura da sentença condenatória e do acórdão impugnado, é possível identificar, ainda, que não houve outros elementos informativos produzidos por fonte independente ou cuja descoberta fosse inevitável, porquanto o contexto da abordagem do ora paciente, aliado aos dados obtidos por meio do acesso ao seu celular e a posterior apreensão de drogas é que formaram a convicção do Parquet pelo oferecimento de denúncia pela possível prática do crime previsto no

art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e o posterior convencimento das instâncias ordinárias pela condenação do réu no tocante à prática do referido delito. 5. A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de violação dos dados armazenados no aparelho celular do paciente e, portanto, violação da sua intimidade e da sua vida privada, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida (art. 5º, LVI, da Constituição da República) e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e a própria ação penal, porque apoiada exclusivamente nessa diligência policial. 6. Uma vez reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da medida invasiva, bem como de todas as que delas decorreram, fica prejudicada a análise do pretendido reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 7. Ordem concedida, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio do acesso ao celular do paciente, bem como de todas as que delas decorreram e, consequentemente, absolvê-lo em relação à prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal (Processo n. 0184051-80.2019.8.19.0001, da Vara Criminal da Comarca de Maricá RJ)" (HC 609.221/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021)

Nesse sentido, a questão central é determinar se, efetivamente, ocorreu o indevido acesso ao celular do acusado e, em caso de ocorrência, se não estaria configurada alguma das hipóteses previstas no art. 157, §1º ou §2º, do CPP.

5.2. In casu, a existência de busca ilegal no aparelho celular do acusado não restou demonstrada.

É que a despeito da violação do sigilo, é necessário observar que a autorização de entrada na residência não é decorrente diretamente da situação envolvendo o celular, de forma que caracterizada a hipótese do art. 157, §1º (parte final) e §2º, do CPP ("§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. § 2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova").

A despeito da ausência de técnica do legislador na redação do art. 157, §2º, do CPP – na medida em que há confusão entre a teoria da fonte independente e da descoberta inevitável – é certo que o ordenamento adotou a ressalva de que quando a prova impugnada (no caso, a descoberta das drogas na residência do acusado) é decorrente de fonte não vinculada à ilicitude, então, sua validade resta preservada.

No caso em análise, é inequívoco que o nexo causal entre a suposta situação de ilicitude e a descoberta das drogas não restou configurado.

Nesse sentido, são todos os depoimentos, prestados em juízo e também em fase de inquérito. Afinal, tais narrativas indicam que a autorização para entrada na residência decorreu de expressa autorização do acusado, diante de seu nervosismo com a situação. Ademais, a própria esposa do acusado afirmou tal situação, dizendo que, ela, também, autorizou a entrada na residência, em decorrência do nervosismo. Isto é, em ambas as narrativas a autorização de entrada na residência não tem vinculação com as mensagens, antes tendo por causa o nervosismo das partes diante da abordagem.

No ponto, veja-se o depoimento do indiciado em fase de inquérito: "Alguns minutos após a abordagem a companheira do indiciado, de nome Lenice, compareceu ao local, já que sua residência é próxima ao local da abordagem. Os policiais começaram a questionar o indiciado sobre a existência de drogas e ele confessou que na sua residência tinha entorpecentes guardados" (fl. 10).

Portanto, o que se verifica é que o celular foi responsável somente por provocar estranheza nos policiais, no momento da abordagem, mas não está vinculado a autorização de entrada na residência. Por este motivo, nos termos do art. 127, §1º, parte final, do CPP, ainda que houvesse alguma violação à garantia do art. 5º, XII, da CF.

5.3. Ainda no ponto, note-se que a tese de que teria ocorrido constrangimento moral da esposa do acusado no momento de concessão de autorização de entrada na

residência, também, não restou caracterizada.

É certo que, no processo penal, nenhum ônus probatório pode ser imposto à defesa. Entretanto, não se pode presumir má-fé dos agentes estatais ou aceitar como válidas quaisquer teses de nulidade, sem qualquer substrato fático. No caso, inexistem ao menos indícios de abuso moral por parte dos policiais, senão as próprias alegações, não comprovadas da informante (esposa do acusado).

5.4. Diante deste cenário, improcedentes as teses de ilicitude das provas.

6. Comprovada a validade do arcabouço probatório, passo a sua análise.

6.1. No ponto, ressalto, em primeiro lugar, que os policiais militares narraram com clareza e de forma detalhada como se deram os fatos. Além disso, não há nos autos indícios de que eles tenham se manifestado de maneira maliciosa e temerária, imputando falsamente à prática criminosa aos acusados. Ao contrário, o que se observa é que os agentes públicos asseveraram com precisão o desdobramento dos fatos, imprimindo certeza e seriedade em suas narrativas.

Neste contexto, a jurisprudência, há muito, já firmou entendimento de que o testemunho dos policiais tem valor idêntico ao de outras pessoas quaisquer que não possuam qualquer interesse no julgamento. Por todos, veja-se o posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência." (HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).

E, também, do STJ:

"3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)." (AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)".

6.2. Nesse cenário, observe-se que os relatos confirmaram a pretensão punitiva descrita na inicial acusatória.

É que pela versão apresentada em juízo é possível concluir que durante patrulhamento os policiais avistaram o acusado, em atitude suspeita, em local conhecido pela comercialização de entorpecentes e ao procederem sua abordagem notaram que constava em seu nome mandado de prisão. Na sequência, o acusado chamou sua esposa, para lhe entregar seu RG e, posteriormente, em razão do nervosismo diante da situação, confessou que tinha drogas em sua residência, autorizando a entrada da polícia e ressaltando o desconhecimento de sua esposa a respeito da situação.

Dessa maneira, entendo que estão comprovadas autoria e materialidade da conduta descrita na exordial.

7. Por esta razão, passa à análise do tipo penal.

7.1. Como se sabe, para a caracterização do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não se faz necessário que o acusado seja surpreendido no próprio ato da mercancia ilícita. Isto porque o tipo penal exposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, é um crime de núcleo misto e alternativo, para o qual basta a configuração de uma das condutas nucleares do tipo para que esteja comprovada a prática penal.

Nesse sentido, observe-se a redação do art. 33, da Lei 11.343/06: "Art.33: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor a venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (grifo nosso).

In casu, a conduta dos agentes se ajusta aos verbos descritos no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, consumando-se o delito com a prática de qualquer uma das hipóteses previstas, na medida em que as condutas se enquadram na forma descritiva dos tipos penais de: "guardar".

Por esta razão, comprovada a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

7.2. Destaque-se, ainda, que impossível a aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o acusado apresenta condenações penais com trânsito em julgado (fls. 143-145) não preenchendo, portanto, o requisito da primariedade.

8. A respeito dos demais elementos dos injustos penais, observa-se que o acusado é imputável, tem a consciência da ilicitude de suas ações, era exigível conduta diversa e não agia amparado por causa excludente de ilicitude, devendo, então, responder pelas ações praticadas, dado que todos os elementos da estrutura analítica dos delitos estão presentes.

9. Passo à dosimetria da pena.

O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, apresenta pena abstrato de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias multa.

8.1. Na análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do CP, não foi possível valorar a conduta social, o comportamento da vítima, a personalidade da agente, em razão da ausência de elementos informativos a respeito de tais vetores. Ainda, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e a culpabilidade são inerentes ao tipo penal.

A respeito dos antecedentes (fls. 143-145), observa-se que o acusado apresenta duas condenações penais com trânsito em julgado. Desta maneira, considerando o cálculo escalonado de dosimetria da pena, previsto no art. 68, do CP, a condenação decorrente dos autos 0003791-31.2016.8.26.0126 (art. 155, §4º, I, II e IV, do CP) será valorada a título de reincidência e a condenação dos autos 0003791-31.2016.8.26.0126 será ponderada nesta fase.

Em relação aos crimes previstos na 'Lei de Drogas', o art. 42 da Lei 11.343/06, estabelece, como circunstâncias preponderantes no contexto da análise da primeira fase da dosimetria, a ponderação da natureza e quantidade de drogas. In casu, a quantidade de drogas, não deve ser sopesada nessa etapa. Isto porque embora não seja desprezível, se encontra consonância com os padrões ordinários verificados na prática deste juízo. Em contrapartida, a natureza das drogas pesa parcialmente em desfavor do acusado, haja vista que uma das drogas apreendidas (crack) é capaz de gerar gravíssimos danos à saúde e implicar em forte dependência química, conforme consenso na comunidade científica.

Desta maneira, conforme o exposto acima, fixo a pena base em: 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

8.2. Passo à segunda fase da dosimetria. Neste momento, analisam-se as circunstâncias agravantes e atenuantes. No caso em análise, presente a agravante da reincidência na forma do art. 63, do CP, em decorrência da condenação nos autos 0003791-31.2016.8.26.0126 (art. 155, §4º, I, II e IV, do CP), conforme acima exposto. Em contrapartida, também presente a atenuante de confissão espontânea, na forma do art. 65, III, d, do CP. Pelo exposto, na forma do art. 67, do CP, tratando-se de reincidência simples e confissão espontânea, devida a compensação das circunstâncias.

Por esta razão, a pena intermediária permanece em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

8.3. Na terceira fase da dosimetria analisam-se as causas de aumento e diminuição. In casu, não se vislumbra nenhuma causa de aumento ou diminuição.

Pelo exposto, a pena definitiva fica em 06 (seis) anos de reclusão e 600

(seiscentos) dias-multa.

9. Tendo em vista o quantum de pena aplicado e a reincidência dos acusados, nos termos do art. 33, §2º, do CP, fixo o regime SEMIABERTO para o início de cumprimento de pena.

Isto porque, a fixação de regime deve seguir a determinação do art. 33, §3º, do CP, o qual dispõe que: "A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". Trata-se, pois, de regra infraconstitucional que procura regulamentar o mandamento constitucional de individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da CF.

Neste contexto, o art. 59, do CP – referenciado pelo art. 33, §3º, do CP – estabelece que a pena será fixada "conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime".

Diante deste contexto normativo, a pena deve ser fixada em vista das características específicas do caso, não sendo obrigatória a imposição de regime mais severo – ainda que juridicamente viável – se uma reprimenda mais branda for suficiente ao atendimento dos objetivos almejados pelo art. 59, do CP.

No caso em análise, não se olvida que a fixação de regime fechado seria juridicamente viável, uma vez que se trata de acusado reincidente, condenado a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos. Entretanto, tal imposição não se faz imprescindível ao atendimento dos objetivos do art. 59, do CP, não sendo, portanto, medida que se impõe.

Conforme fundamentado acima, é inerente ao conceito de democracia a ideia de que toda imposição de pena deve ser fundamentada e também necessária (ver ainda: MILL, John Stuart. Sobre a Liberdade. Lisboa: Edições 70, 2014, p. 77-86). No caso, não sendo a imposição de regime fechado circunstância imperiosa à satisfação do art. 59, do CP, não há razões que conduzam à obrigatoriedade do regime mais severo – ainda que este seja juridicamente cabível.

10. O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese, notadamente para o fato delituoso em comento, relativo ao bom comportamento carcerário (art. 112 da LEP) que, in casu, não é do conhecimento profundo deste Juízo.

11. O valor do dia multa será calculado no valor unitário mínimo (art. 43 da Lei nº 11.343/2006), haja vista a inexistência de provas a respeito de riqueza, e deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, desde a data da infração.

12. Em vista do quantum de pena aplicado, inviável a aplicação dos art. 44 e art. 77, do CP.

Ante o exposto, com fundamento no art. 387, do CPP, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR os acusados LEANDRO ALVES DOS SANTOS pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, com atualização monetária, nos termos da tabela do e. TJ-SP.

Tendo em vista que a sentença penal não tem por consequência alterar de maneira automática e imediata a condição processual/prisional deixo de proceder com alterações a respeito das medidas cautelares. Ademais, no ponto, destaque-se que em vista dos fundamentos acima apresentados e da ausência de alteração a respeito da situação fática dos acusados, a prisão preventiva se mantém válida e necessária. Entretanto, considerando a pena aplicada, o regime prisional imposto e o conteúdo da Súmula 716, do STF (in verbis: "admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória"), entendo que, embora a custódia cautelar deva ser mantida, uma vez que os requisitos da medida permanecem existentes e legítimos, é devida a progressão ao regime semiaberto – caso o acusado não esteja em regime fechado em razão de outros motivos e autos. EXPEÇA-SE O MANDADO DE PRISÃO CORRESPONDENTE.



Na forma da Lei Estadual nº 11.608/2003 e art. 804, do CPP, condeno a acusada ao pagamento das custas processuais, observada gratuidade de justiça que ao momento se defere.

Serve a presente decisão como ofício/mandado/intimação.

Nos termos do art. 50-A, da Lei 11.343/2006, DETERMINO a incineração das drogas apreendidas, sendo tomadas as devidas cautelas legais.

Nos termos do art. 61, da Lei 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos, uma vez que comprovada suas vinculações com os delitos. Seja procedida com a destinação devida, nos termos da lei.

Após o trânsito em julgado:

i. Comunique-se a Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal;

ii. Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal;

iii. Oficie-se ao I.I.R.G.D., noticiando desta condenação.

iv. Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu;

v. Expeça-se guia de execução penal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Caraguatatuba, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA